

1500179-52.2021.8.26.0573

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Érica Regina Figueiredo

Comarca: São Manuel

Foro: Foro de São Manuel

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 08/02/2022

... - Rel. Min. Carmen Lúcia), entendeu-se que a figura do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, parágrafo 4º da Lei nº 11.343/06, não se harmoniza com a qualificação de hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e parágrafo 1º do artigo 33 do mesmo Diploma.

Muito embora possam existir respeitáveis discussões acadêmicas quanto ao mérito da referida decisão, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Manuel

Foro de São Manuel

2ª Vara

Rua Ettore Targa, s/n, São Manuel - SP - cep 18650-000

1500179-52.2021.8.26.0573 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500179-52.2021.8.26.0573

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TALES BARBOSA DIAS

Vistos.

TALES BARBOSA DIAS, qualificado nos autos digitais, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque no dia 19 de junho de 2021, por volta da 12h45min, na Rua Octacílio Nogueira, nº 990, Área Rural, na cidade de Pratânia, Comarca de São Manuel, o acusado guardava e tinha em depósito 30 (trinta) papérolas de crack, pesando 14,36g (quatorze gramas e trinta e seis centigramas), 31 (trinta e um) pinos de cocaína, pesando 34,35g (trinta e quatro grama e trinta e cinco centigramas) e 34 (trinta e quatro) porções de maconha, pesando 83,99g (oitenta e três gramas e noventa e nove centigramas), drogas destinadas ao consumo de terceiras pessoas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão e laudo de constatação provisório juntados aos autos.

O réu foi preso em flagrante delito e o expediente policial distribuído ao Juízo Plantonista da 23ª CJ que, após as manifestações das partes, decidiu pela conversão de liberdade provisória com a fixação de medidas cautelares. (p.61/64)

Oferecida a denúncia, foi determinada a notificação do acusado nas p.108/109.

O réu foi devidamente notificado nas p.123 e ofereceu defesa preliminar nas p.131/133, sendo a denúncia recebida por decisão datada de 17 de agosto de 2021 (p. 138/139).

Durante a instrução, realizada por videoconferência consoante o disposto na Recomendação CNJ n.314/2020, Provimentos n. 2557/2020 e 2564/2020 e Comunicados CG 284/2020, 317/2020 e 581/2020, foi ouvida uma testemunha arrolada na denúncia e interrogado o réu ao final, conforme mídia de gravação audiovisual juntada nas p.168.

Encerrada a instrução criminal, a i. Representante do Ministério Público, por meio de alegações finais orais, requereu a condenação do acusado nos termos da exordial. A n. Defesa técnica do réu, a seu turno, por memoriais escritos, pugnou por sua absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, em caso de condenação, postulou pela aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33 da Lei de Drogas (p. 169/175).

É o breve relatório.

DECIDO.

Não havendo questões preliminares ou de admissibilidade a analisar e, no mais, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame do mérito.

A procedência do pedido inicial é medida que se impõe, vez que devidamente provadas à materialidade dos fatos e a sua autoria.

Com efeito, a materialidade restou suficientemente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante de p. 04/05, Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida de p. 06/07, Auto de Exibição e Apreensão de p. 10/11, Laudo Químico-Toxicológico Definitivo de p. 117/119, que atestou a natureza entorpecente das substâncias apreendidas com resultado positivo para cocaína, cocaína na forma de crack e Cannabis Sativa L-maconha.

No tocante à autoria, observo que o réu Tales Barbosa Dias, quando ouvido em solo policial, admitiu que guardava as drogas apreendidas e sua destinação ao comércio a terceiros por estar desempregado. (p.12/13)

Já quando quando interrogado em juízo, negou a propriedade das drogas apreendidas, alegando quenada de ilícito foi apreendido pelos policiais em seu poder, apenas quantia de R\$90,00, proveniente de seu trabalho na colheita de laranjas. Que após sua abordagem, o policial foi até um terreno e encontrou várias porções de crack e negou ter indicado aos policiais onde estava o restante da droga que foi localizada e apreendida.

Maicon Henrique Vitti, policial militar, relatou que realizava patrulhamento de rotina ,quando o avistou o acusado, já conhecido dos meios policiais pela prática da traficância, saindo de um terreno baldio, local conhecido como ponto comum de tráfico. Que ao avistar a viatura policial, o réu dissimulou e se sentou na mesa de um comércio, razão pela qual foi abordado e revistado, porém nada de ilícito foi encontrado em seu poder. O réu não soube responder o que estava fazendo no terreno de onde foi visto sair e ficou nervoso. Que se dirigiu até o terreno e localizou uma grande porção de cocaína ou maconha e, diante disso, voltou a questionar o acusado, que acabou indicando outro local do terreno onde foram apreendidas porções de crack, cocaína e maconha. Disse que acusado assumiu, ainda no local, a propriedade e a comercialização de toda droga apreendida, alegando que estava desempregado, sendo de seu conhecimento que ele atuava a mando de um traficante que acabou sendo preso posteriormente e, ao que se recordou, também foi apreendido dinheiro.

Pois bem.

A cabo da instrução criminal, nota-se que a negativa de autoria sustentada pelo réu em Juízo, negando a propriedade e comercialização da droga apreendida, além de inconvincente, restou totalmente isolada e sem amparo nos demais elementos de prova coligidos nos autos, muito mais favoráveis à acusação.

Isso porque o policial militar ouvido foi firme e convincente ao declarar que o réu, já conhecido dos meios policiais pela prática do tráfico ilícito de entorpecentes, foi inicialmente visto saindo do terreno onde a droga foi, logo depois, localizada, tendo ele admitido sua posse e comercialização no momento da abordagem, como durante sua oitiva policial, sem, contudo, apresentar em juízo qualquer justificativa para ter confessado a prática do tráfico na Delegacia de Polícia, oportunidade na qual, inclusive, narrou detalhadamente os motivos pelos

quais realizava a traficância.

E as declarações do policial militar Maicon Henrique Vitti, ouvido em juízo, encontram-se em perfeita harmonia com as declarações do também policial militar Carlos José Ferreira dos Santos, ouvido em solo policial nas p.09.

Oportuno consignar que os policiais, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, são merecedores de confiança, como de resto qualquer pessoa há de merecer e, efetivamente, merece, até que se prove o contrário.

A respeito do tema a jurisprudência:

"É assente nesta Corte o entendimento no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso (HC 165.561/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 15/02/2016). Súmula nº 568/STJ. [...] 8. Habeas corpus não conhecido." (HC 393.516/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe 30/6/2017)." (STJ - HC: 530794 SP 2019/0261161-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: DJ 06/08/2020).

Saliente-se não haver nos autos qualquer indício de animosidade prévia entre o réu e o policial militar ouvido de modo a demonstrar que queira prejudicar pessoa inocente, imputando-lhe a prática de crime saber inexistente, mormente diante do notório risco de eventual responsabilidade pelo crime de abuso de autoridade ou de denúncia caluniosa.

Ademais, é cediço que a prova do tráfico deve ser extraída das diversas circunstâncias do delito, como no presente caso.

Isso em razão do réu ter sido visto pelos policiais deixando um terreno baldio, sem apresentar qualquer justificativa convincente do que estava fazendo naquele local, onde, na sequência, foi apreendida elevada quantidade de droga pronta para a venda, além da apreensão de quantia em dinheiro seu poder, sem qualquer comprovação nos autos de sua origem lícita.

Evidente que, cada um destes elementos, isoladamente, não ensejaria a condenação. Mas a reunião de todos eles, por óbvio, leva a certeza da prática do tráfico pelo réu no qual se concluiu, sem dúvidas, que seu objetivo era a comercialização de entorpecentes, o que, segundo os policiais, foi admitido pelo acusado no momento da abordagem.

Ressalte-se que o delito em tela restou plenamente consumado ainda que o réu não tenha efetivamente comercializado drogas em virtude da pronta e eficiente ação da polícia que o prendeu em flagrante antes disso, já que o artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 prevê um tipo penal de ação múltipla alternativa, de modo que a realização de apenas uma das condutas nele descritas já é suficiente para a sua configuração, tendo o acusado praticado duas delas, tanto guardava, como tinha em depósito drogas destinadas ao consumo de terceiras pessoas.

A ratio legis pretende antecipar a proteção ao bem jurídico saúde pública, não exigindo a ocorrência de um dano concreto, mas tão somente uma situação onde: ocorra perigo à saúde de um grupo indeterminado de pessoas.(REsp 1708569, Rel. Min. Ribeiro Dantas, data de publicação: 06/03/2018).

Em remate, diante do conjunto probatório coligido nos autos, não resta a menor dúvida da traficância praticada pelo acusado.

Passo a dosar as penas.

Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei n. 11.343/06, notadamente a primariedade do acusado, conforme se observa da certidão de p.100 e de sua F.A. de p.102/104, fixo a pena base no mínimo legal, a saber, 5(cinco) anos de reclusão e 500(quinzentos) dias multa.

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a considerar, tampouco causas de aumento de pena.

Presente a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, pois o réu é tecnicamente primário, não ostenta condenações criminais anteriores, além de inexistir nos autos prova de que se dedique à atividades criminosas ou integre organização criminosa, não bastando para afastá-lo as declarações do policial ouvido de que ele já era conhecido dos meios policiais.

Assim, por força do §4º, do artigo 33, Lei nº 11.343/06, diminuo a pena em 3/5(três quintos) diante da expressiva quantidade de porções de drogas que poderiam atingir quase uma centena de usuários e sua variedade, dentre elas cocaína e crack, de alto poder viciante e com a produção de efeitos nefastos ao usuário, resultando em 2(dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, tornando as penas definitivas em tal patamar.

A míngua de maiores elementos sobre a situação econômica do réu e diante da sua aparente hipossuficiência, fixo no patamar mínimo o valor do dia-multa.

Quanto ao regime prisional inicial, observo que na decisão proferida pelo Plenário da Corte Suprema (STF - HC 118.533/MS - Rel. Min. Carmen Lúcia), entendeu-se que a figura do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, parágrafo 4º da Lei nº 11.343/06, não se harmoniza com a qualificação de hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e parágrafo 1º do artigo 33 do mesmo Diploma.

Muito embora possam existir respeitáveis discussões acadêmicas quanto ao mérito da referida decisão, entendo, com a devida ressalva a entendimentos contrários, que não cabe a este Juízo deixar de reconhecer força a referido precedente, igualmente adotado pela 3ª Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso repetitivo cadastrado como Tema 600, cancelando, por consequência, a Súmula n. 512, editada em 2014.

Assim sendo, curvo-me ao entendimento jurisprudencial pacificado para reconhecer o afastamento da hediondez da conduta do acusado e, por consequência, fixar o regime aberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, à luz do que dispõe o artigo 33, §3º, do Código Penal.

No que diz respeito à substituição da pena corporal por restritivas de direitos, apesar da recente Resolução nº 5 editada pelo Senado Federal, através da qual ficou suspensa a expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", presente no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, a mesma não se mostra medida suficiente e adequada no caso concreto, haja vista a postura indiferente adotada pelo agente diante dos efeitos nocivos do crime de tráfico de drogas à saúde pública e ao bem estar social, o que vai de encontro com o requisito previsto pelo inciso III, do artigo 44, do Código Penal: "Na espécie, a natureza, a quantidade e diversidade da droga apreendida não recomendam a substituição da pena, nos termos do inciso III do art. 44 do Código Penal, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade na negativa da benesse em tela. Precedentes." (HC 506.963/SP, j. 21/05/2019)

Vale lembrar que os requisitos previstos no artigo 44, do Código Penal, são cumulativos, devendo estar integralmente presentes para que seja concedida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o que não se verifica na espécie, sendo, portanto, inadmissível.

Deixo de fixar indenização por danos materiais em valor mínimo, pois o delito em apreço não gera efetivo prejuízo material mensurável economicamente.

Por fim, considerando o término da instrução criminal, o montante da pena aplicada a ser cumprida no regime inicial aberto, mantenho a liberdade concedida ao réu, a fim de que aguarde solto eventual interposição de recurso e o trânsito em julgado. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para CONDENAR o réu TALES BARBOSA DIAS, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, c.c. o §4º, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 2(dois) anos de reclusão, no regime inicial aberto, e pena pecuniária de 200 (duzentos) dias-multa, calculados no mínimo legal, facultando-lhe o apelo em liberdade.

Após o trânsito em julgado, arcará o réu com as custas processuais no valor correspondente à 100 UFESP's.

Sem prejuízo, porque não comprovada a origem do numerário apreendido nos autos (p.89), declaro sua perda em favor da União (Lei 11.343/06, artigo 63)

Observe-se o contido no artigo 400das NSCGJ, se o caso.

Por fim, considerando que a prova oral não comprovou que o aparelho celular apreendido nos autos estava sendo efetivamente utilizado na prática do tráfico ou foi adquirido com recursos de origem ilícita, tampouco houve requerimento para elaboração de prova pericial nesse sentido, após o trânsito em julgado o presente decisum (CPP, artigo 118) e, uma vez comprovada documentalmente sua propriedade,

fica desde já deferida sua restituição.

Com o trânsito em julgado, oficie-se para destruição das amostras guardadas para contraprova conforme o disposto no art. 525 das NSCGJ-Encerrado o processo penal ou arquivado o inquérito policial ou termo circunstanciado, o juiz determinará a destruição das amostras guardadas para contraprova, não podendo os autos serem remetidos ao arquivo sem a respectiva comunicação.

P. I.C.

São Manuel, 08 de fevereiro 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA